

CONTRATOS INFORMATICOS

I

1.- Introducción: Concepto y caracteres del contrato informático

La irrupción de nuevas tecnologías tendientes al tratamiento, almacenamiento y recupero de la información, dieron lugar a figuras contractuales diversas que pronto adquirieron características propias, las cuales generaron nuevos institutos jurídicos y principios privativos de dichos negocios jurídicos.

El concepto de contrato informático en nuestra doctrina se relaciona con todos aquellos negocios jurídicos que tienen por objeto los sistemas destinados a la gestión organizada de información. Mosset Iturraspe¹ define al instituto como “... *la operación jurídica mediante la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen relaciones obligacionales sobre bienes y/o servicios informáticos. Estos bienes se integran generalmente en un sistema, que el conjunto de elementos materiales o inmateriales, ordenados e independientes, vinculados con un objetivo común*”.

Para Bergel los aspectos singulares de la contratación informática son los siguientes: a) Acentuación de la distancia entre el proveedor y el cliente b) Diferencias en los objetivos de las partes al contratar c) Dificultades en la individualización del objeto contractual d) Parámetros relativos al incumplimiento de la prestación e) problemas suscitados con la redacción f) Predominio de contratos mixtos y con cláusulas predispuestas².

El problema de la definición del objeto: El concepto de sistema

La definición de Mosset Iturraspe, delata la existencia de una particularidad de los contratos informáticos, como es la interrelación de los elementos disímiles que conforman el objeto del negocio en un sistema ordenado destinado a la concreción de un bien concreto. Esta característica de sistema, tal como fue receptado en nuestra jurisprudencia en el caso “*Sisteco, Sistemas de computación S.A. c/ Sujoy Sergio*”³, plantea una nueva característica de los contratos de provisión de servicios informáticos, como es la diferenciación en la causa final de los contratantes.

Debe tenerse en cuenta que a diferencia de, verbigracia, una compraventa tradicional la intención de el usuario y el suministrador de un servicio informático se aproximan al negocio jurídico con intenciones opuesta, toda vez que mientras que el primero tiene la intención de obtener un resultado determinado, el segundo solamente se compromete a la entrega de un universo de bienes con determinadas especificaciones técnicas.

Dicho de otro modo, mientras que el usuario intenta obtener una funcionalidad determinada, el proveedor busca la comercialización de un conjunto de bienes materiales e inmateriales. Se podría argumentar que esta característica se repite en la mayoría de los contratos de consumo, pero con una salvedad: Un ordenador no mantiene una funcionalidad ontológica sino que depende de su configuración. A diferencia de, verbigracia, un televisor, un sistema informático no cumple una función específica sino que depende del hardware que lo constituya, los programas que se encuentren instalados, la conectividad con que cuente. Pensemos simplemente en una pc hogareña y veremos que las configuraciones posibles son múltiples: ¿Vamos

¹ Mosset Iturraspe, “*La Excepción de Incumplimiento en el contrato informático y la condena condicional*”, La Ley, T 1991- A, Pag. 402 y siguientes

² Bergel Salvador Darío, Notas sobre la contratación informática, RDPC, N° 3, pags. 185 y sigs.

³ La Ley, T 1987 -A, Sección Jurisprudencia, páginas 136 y siguientes.

a realizar tratamiento de imágenes? Entonces necesitaremos más memoria, buena impresora y el software adecuado (photoshop, autocad, etc). ¿O simplemente navegaremos por Internet y consultaremos el correo? ¿Tiene sentido la adquisición de una placa de video de alta gama si no pensamos utilizar los últimos juegos salidos al mercado?

El concepto de sistema permite unificar los componentes informáticos en una universalidad definida por su función. Sistema será, entonces, el conjunto de bienes que permitan realizar la tarea específica solicitada por el usuario, de forma tal que la mera entrega de los componentes no satisface la obligación del proveedor sino que se hace necesaria su puesta en funcionamiento y la satisfacción de la necesidad del usuario

A esto último debe sumársele notoria diferencia en el conocimiento que sobre el objeto de la contratación poseen las partes. Tal como reiteradamente lo han hecho notar la doctrina y jurisprudencia⁴, el usuario no posee el conocimiento técnico necesario para una toma de decisión fundada, sino que debe confiar en la información suministrada por el proveedor, quien ejerce, *de facto*, un monopolio sobre la información material y técnica que dará lugar al negocio jurídico.

Frente a esta realidad, es necesario encontrar una solución jurídica que permita no solo compatibilizar los intereses dicotómicos de las partes sino eliminar la brecha tecnológica que las separa, volviendo a establecer la igualdad negocial.

La obligación de información: Concepto

En los contratos informáticos, tal como se ha dicho, tienen por objeto principal una universalidad de bienes materiales e inmateriales compleja conocida como **sistema**, la cual tiene un componente teleológico, que le sirve de definición y sustento.

Atento a ello, un sistema informático solo es útil cuando sus objetivos han sido definidos claramente por parte del usuario, así como cuales son los impactos que sobre la organización y la empresa se han de producir. Como contrapartida, es obligación del proveedor de los bienes el asesoramiento y consejo respecto a la tecnología a incorporar a los efectos de que el sistema efectivamente adoptado guarde relación con los fines requeridos por el usuario.

Todo ello es en realidad una derivación de la buena fe con que las partes deben concurrir al acto contractual, que se traduce en un deber de colaboración entre ambos a los efectos de definir los componentes y extremos del sistema.

El Deber de Asesoramiento y Consejo.

Concepto y Fundamentos: El deber de asesoramiento y consejo en cabeza del proveedor de sistemas de información se relaciona con la determinación del objeto de contrato, así como el en la concordancia entre los fines pretendidos por el usuario y la prestación final del proveedor.

Atento, tal como se ha manifestado anteriormente, la existencia de una disparidad de conocimiento tecnológico entre el proveedor y el usuario, es obligación

⁴ En particular ver Almark, Daniel “*Contratos Informáticos. El contrato de mantenimiento*” en Rev. La Ley, T 1986-B, pag. 719, Messina de Estrella Gutierrez “*Asunción de las realidades tecnológicas -informática - por el proyecto de unificación civil y comercial*”, La Ley T 1988- A, Pag 734. y jurisprudencialmente, *Sistex S.A. c/Oliva S.A. Valerio*”, La Ley, T 1991-A, voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci

del primero aconsejar y ayudar a la determinación de las características del sistema de forma tal que se adecuen a los objetivos propuestos por este último.

Ya la Corte de Casación Francesa en el año 1971, en autos “*Soc. Bourroughs vs. Société A del Prete y Locafrance*” señaló la obligación del usuario de responder en los casos de que el sistema desarrollado no cumpla cabalmente con los objetivos solicitados por el usuario, siendo indiferente a los efectos de definir la responsabilidad si los distintos componentes del mismo funcionaban o no correctamente.⁵

Cabe en cabeza del proveedor de servicios, entonces, la necesidad de informar en forma cierta y objetiva las características del objeto del contrato, de forma tal que evite la contratación de sistemas insuficientes a los efectos de la tarea a realizar, así como aquellos cuyo costo y prestaciones superen ampliamente las necesidades, generando un costo injustificado en cabeza del usuario.

Nuestra Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 4º impone a los empresarios el deber de suministrar a los consumidores, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada y suficiente sobre las características esenciales de los productos o servicios comercializados. Esto conlleva una relevancia práctica que radica, principalmente, en la influencia que la información retaceada o falseada ejerce sobre el consentimiento, toda vez que la misma ley prevé la posibilidad de sanciones de nulidad ante la infracción a dichos principios.

En realidad, tanto la obligación de consejo como el deber de información al consumidor, no son mas que la aplicación a distintos campos del derecho de principio de la buena fe contractual consagrado en el artículo 1198, que sostiene que en materia de contratos, ellos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosimilmente entendieron o pudieron entender.

Siguiendo la terminología de Spota, debe distinguirse entre la buena fe-creencia de la buena fe-lealtad, siendo esta última el deber de actuar con probidad, como lo haría una persona honorable y correcta, obrando con cuidado y previsión.

Por ende, y aplicando dichos principios al caso concreto, la partes deben recíprocamente, consideración y lealtad en punto a sus mutuas esferas de interés, evitándose errores, a cuyo efecto es regla esencial la del *clare loqui*, y la obligación de evitar caer en reticencias que, de haber sido manifestadas, habrían obstado a la concreción del contrato o por lo menos hubieran impulsado su modificación.

Dicho requisito de buena fe se traduce en los contratos informáticos en la obligación del profesional, quien detenta el monopolio de la información técnica, de no abusar de su posición dominante, debiendo traducir fielmente las necesidades del cliente en términos de la tecnología a aplicar. Debe tenerse en cuenta que la existencia de o no de diferencias económicas es indiferente a los efectos de la presente obligación : El desequilibrio negocial de las partes se produce atento a la presencia de una parte lega en la materia y otra experta, sin importar, prima facie, las diferencias económicas de las partes.

Contenido : El contenido del deber de consejo se circunscribe a lo que sea relevante y suficiente, con miras a la toma de una decisión. De lo anteriormente dicho, se desprende que la obligación de consejo mantiene una doble faz : Una activa, en tanto es obligación del proveedor la determinación de las características técnicas esenciales del contrato, así como la explicitación de los riesgos a asumir

⁵ En el mismo sentido, “*Société Flammarion y Cia vs Société IBM France*” de 1972, ambos citados en Bergel, Salvador Dario, “*Informática y Responsabilidad Civil*”, Colección Informática y Derecho, Tomo 2, Pags 157 y siguientes.

por el usuario, y otra pasiva o de abstención, al imponer en cabeza de este la obligación de no ser reticente u ocultar información pertinente al contrato.

Si bien dicha obligación no se encuentra legislada en nuestro derecho, debe tenerse en cuenta lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor cuando exige que la información suministrada a los consumidores y usuarios, sea veraz detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de la prestación.

La veracidad de la información esta referida a la sinceridad con que debe ser emitida: La información no es veraz cuando su contenido es engañoso, particularmente cuando silencia datos esenciales, creando en el destinatario expectativas que no son factibles de ser satisfechas o cuando induce a error por omisión de circunstancias relativas a la prestación.

Que la información sea detallada, implica la necesidad de que el consumidor tenga la posibilidad de informarse acerca de las auténticas características de los productos y servicios que le son ofrecidos. Debe tenerse en cuenta en lo relativo las contrataciones informáticas que dicha información debe ser relacionada con las necesidades expresadas por el usuario: No es la mera enunciación de las características técnicas de los equipos y software a utilizar, descripción que en la mayoría de los casos se encuentra más allá de la posibilidad de comprensión del operador final, sino básicamente como estos posibilitan la concreción de los objetivos propuestos en el estudio de necesidades del usuario.

La eficacia de la información está referida a la potencialidad disuasoria, es decir la capacidad de generar una decisión en cabeza del usuario, creando una relación de causalidad entre la emisión de la información y la celebración del contrato. Demás esta decir que dicha información debe cumplir con los requisitos de veracidad y autenticidad anteriormente analizados.

La suficiencia sobre las características esenciales de las prestaciones o servicios ofrecidos alude a la necesidad de que los detalles, descripciones y especificaciones sean aptos para habilitar al consumidor a tomar una decisión reflexiva con conocimiento de causa. La ausencia de dicho requisito implica una maniobra dolosa de ocultamiento de información pertinente que podría generar dolo en la voluntad del contratante.

La importancia de la cuestión radica fundamentalmente en los casos en los que la falta de información suficiente determinó el consentimiento, imponiendo la contratación de servicios que de otra forma no hubieran sido celebrados.

La jurisprudencia francesa en varias oportunidades ha tenido ocasión de analizar el tema. En el caso "*Olivetti e. Karpathios*", entre otros, la Cámara de Casación francesa revocó la contratación por entender que el sistema proveniente por la firma Olivetti consistente en tres programas de facturación, stock, y registro de pagos no resultaban compatibles entre sí y por ende la empresa había incumplido su deber de consejo, atento que el sistema entregado no cumplía los objetivos propuestos por la parte usuaria⁶.

Debe tenerse en cuenta que nuevamente este fallo pone de manifiesto la relación existente entre las necesidades del cliente y la obligación de aconsejar por parte del proveedor de servicios informáticos. Es la ausencia de correlación entre el objetivo propuesto y el sistema entregado compromete la responsabilidad del profesional interviniente. Es obligación de este último no solo la provisión del material informático sino que debe necesariamente convertirse en interprete de la voluntad del usuario traduciéndola en un sistema capaz de satisfacerla.

⁶ En el mismo sentido "*Deslandes et Thurler c. Burroughs*", y "*Faberge c. Chauvin*" ambos citados en Altmark, Daniel Ricardo y Molina Quiroga, Horacio, "*Contratos Informáticos. La Etapa Precontractual*."

Naturaleza Jurídica: Cabe preguntarse asimismo sobre la naturaleza jurídica de la obligación. En el caso de la presente, como obligación de hacer, es menester dilucidar si la misma constituye una obligación de resultado o de medio, según se haya prometido un cambio en el estado de hechos determinado o tan solo la puesta disposición del acreedor de los medios tendientes a la concreción de dicho fin.

Dicha cuestión tiene, mayor importancia en lo referente a la prueba, atento al hecho que si entendemos a esta obligación como de resultado, la mera demostración de inexistencia de adecuación, daría lugar a la condena.

En general y atento a la disparidad de conocimientos informáticos anteriormente analizada, como a la ausencia de injerencia por parte del usuario en la elaboración de la oferta, el autor de la presente se inclina a considerar a la misma como de resultado, atento que atento a la divergencia debe presumirse que la misma fue responsabilidad del proveedor.

Sin embargo, dicha obligación termina en la elaboración del consejo, por lo que debe eximirse al proveedor de la responsabilidad de decisión final del usuario : El contenido de la obligación de consejo se satisface con la expresión de una información veraz, eficiente, detallada y suficiente del sistema propuesto a los efectos de la toma de la decisión, siendo independiente de la decisión final de usuario : Lo que ampara ordenamiento es el derecho a tomar decisiones con conocimiento de causa y no el derecho a tomar malas decisiones.

De igual manera la existencia de diferencias entre lo aconsejado y lo finalmente ejecutado, podrán dar lugar a responsabilidades contractuales por falta de cumplimiento de lo pactado o vicios redhibitorios pero no por la obligación de consejo, toda vez que la misma se agota en la emisión de la oferta o subsiguientemente con cada una de las opiniones formuladas por el proveedor a lo largo del contrato.

Por todo ello, es conveniente, en particular en la etapa precontractual, la elaboración de actas de intención, minutas u ofertas por escrito, donde se deje asentado la oferta realizada por la parte profesional, a los efectos de poder, en caso de conflicto, dilucidar las respectivas responsabilidades

La jurisprudencia francesa ha evolucionado considerando en una primera etapa a la obligación como de resultado, para posteriormente considerar a la misma como simplemente de medios. Así en 1971, señaló que el proveedor podía ser responsabilizado por el hecho de que el sistema no era adecuado aunque materialmente el material -material y software- estuviera en buenas condiciones funcionamiento⁷. Sin embargo, posteriormente, el mismo tribunal sostuvo in re “*Société Flammarion y Cia. vs. Société I.B.M. France*” que el operador no puede ser responsabilizado por el éxito total de la operación de informatización, toda vez que el resultado depende de la calidad misma del material y las condiciones en que el material ha sido implementado⁸.

El autor de la presente disiente con la interpretación de la Corte de Casación, atento que la misma relaciona la obligación de consejo con el resultado final de la informatización. Debe tenerse en cuenta que la misma es una obligación de información y satisface con la correcta manifestación al usuario: si la responsabilidad se deriva de un error en la implementación de lo aconsejado o de un riesgo previsto y aceptado por las partes, estaríamos en un campo ajeno al deber de consejo. Mismo es el caso en que estemos frente a una situación de fuerza mayor, en la

⁷ In re “*Soc. Bourroughs vs Société A del Prete y Locafrance*”, de 1971

⁸ “*Société Flammarion y Cia. vs. Société I.B.M. France*” de fecha 12/2/72, citado en Bergel, Salvador Dario, Op. Cit nota 4

responsabilidad de las partes se excusa. Si, en cambio, la deficiencia se deriva en la ausencia de previsión de los riesgos de la cosa, indudablemente la información ha sido deficiente y por ende el proveedor debe responder. No debemos olvidar siempre que se produce un daño, existe un responsable. Si sostenemos que los riesgos inherentes a la cosa no deben ser tenidos en cuenta al formular el consejo, estaríamos perjudicando a la parte cuya falta de formación técnica le ha impedido prever el problema, en beneficio de la parte profesional, de quien se espera la mayor diligencia.

El deber de colaboración. La elaboración de Cuadro de Necesidades. El equilibrio en las contraprestaciones:

La existencia de los anteriormente referidos deberes por parte del proveedor del servicio no significan dejar al usuario en una situación pasiva. Tal como se expresare al definir la obligación de informar, recaen en cabeza del usuario ciertos deberes de diligencia a los efectos la conclusión fructífera de la relación contractual.

Esto es particularmente importante durante la etapa precontractual atento que, en virtud del principio de la buena fe, es cuando ambas parte deben entablar un dialogo a los efectos de definir cuáles son los elementos necesarios de satisfacción.

Es el usuario quien debe definir cuales son los elementos a informatizar así como las situaciones de hecho y características organizacionales sobre los cuales dicha informatización producirá.

La jurisprudencia tradicionalmente ha puesto en cabeza del futuro utilizador la carga del análisis a fin de conocer o hacer conocer sus objetivos exactos y sus necesidades correspondientes. Es este quien debe proveerse de la información necesaria sobre las facetas de su organización, así como la carga y condiciones en que la tarea a informatizarse debe llevarse a cabo. Una falta en este análisis puede llevar a plantear necesidades que no se condicen con la realidad y la formulación de un sistema deficiente o sobredimensionado, con los consiguientes perjuicios para sí. Cabe preguntarse cual es la responsabilidad que le incumbe a la parte usuaria y por defecto a la proveedora.

Resulta interesante a este respecto analizar la postura de la jurisprudencia francesa al respecto de la cuestión. Hasta 1979, los tribunales galos habían sostenido la exclusiva responsabilidad del cliente en cuanto a la formulación de su cuadro de necesidades. Sin embargo en dicho año, la corte de París sostuvo que si bien es obligación del cliente la formulación de sus necesidades, es obligación del proveedor el ayudar a la formulación de las mismas corrigiendo los errores que según su conocimiento las mismas pudieran tener. En realidad, se trata de un proceso de colaboración en el cual cada parte debe cumplir un rol: el usuario debe expresar los objetivos y problemas que el sistema debe tender a solucionar, al mismo tiempo es el proveedor quien debe encauzar las mismas, traduciéndolas en las especificaciones técnicas que constituyen su oferta.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la obligación del usuario de elaborar su cuadro de necesidades debe cumplir con el estándar que el código establece como un buen hombre de negocios y, por ende, si las circunstancias lo aconsejan, debe concurrir a un asesor externo a los efectos de poder identificar y definir sus necesidades⁹. Cabe preguntarse entonces si existen variaciones en función de la presencia de dichos asesores e incluso si existe eximientes de

responsabilidad en el caso de que el usuario sea por si mismo un experto o detente suficientes conocimientos en el campo de la informática.

Debe tenerse en cuenta que en dichos casos la diferencia analizada entre lego y profesional se disipa, al encontrarse frente a una situación en la que los niveles de conocimiento se equilibran, permitiendo la recomposición *de facto* de la igualdad negocial.

De esta manera *in re* “*Ste. Sopresur N.C.R. vs Sté Groupe Lebrun*”¹⁰, la cámara 5º de París resolvió que el proveedor limitaba su responsabilidad, si el cliente habría contratado los servicios de una firma consultora especializada en el tema, quien había elaborado el pliego de condiciones sobre el cual se realizó el contrato.

En dicho caso la responsabilidad del proveedor se limita al cumplimiento del pliego de condiciones como asimismo a proveer la información solicitada por la consultora. En dichos caso en opinión del autor de la presente, nos encontraríamos frente a un caso de transferencia de la responsabilidad desde el proveedor hacia la consultora quien debe hacerse responsable frente al usuario a título de incumplimiento contractual por los defectos en la confección de los pliegos.

En referencia de un usuario entrenado en la utilización de la tecnología, no parece procedente imputar al proveedor con la obligación de consejo: nuevamente nos encontramos frente a un usuario calificado, capaz de entender por si mismo los términos de la oferta.

La jurisprudencia francesa ha entendido como un usuario calificado a aquellas personas que cuentan en su organización con un departamento de informática o en aquellos casos en que la negociación no se ha realizado sobre materiales informáticos de primera generación. En dichos supuestos, se ha sostenido, la obligación de consejo del proveedor se halla reducida.

Por último, es menester definir la naturaleza jurídica de el deber de información de las necesidades por parte del usuario. Al respecto cabe preguntarse si nos encontramos frente una verdadera obligación o simplemente frente a una carga. El concepto de carga, que nace del derecho procesal, es definido por el maestro Couture como “*un imperativo en el propio interés*”¹¹. La carga, a diferencia de una obligación, constituye un débito sin acreedor: La ausencia o incumplimiento de la misma no generan perjuicios o beneficios sino para la persona a cargo de la cual de encuentra el cumplimiento y por ende carece de sujeto que puede exigir su cumplimiento forzoso.

Sobre el particular cabe preguntarse si es posible por parte del proveedor exigir la corrección o entrega de un cuadro de necesidades al que considera falso o deficiente. Más allá de plantear la situación, dejando a salvo su responsabilidad, no parece existir daño en el incumplimiento: El resultado final de dicho proceso no perjudicaría a nadie más que al usuario, quien se encontraría frente a un sistema inadecuado.

La posibilidad de un inicio de acciones a los efectos del cobro de lo pactado, en los casos que existiera negativa de abonarlo por parte del usuario, no convierte al deber de informar en una obligación, toda vez que no existe identidad de objeto: El fin del proceso no sería la corrección del cuadro de necesidades sino simplemente el cobro de un trabajo realizado. La improcedencia de una excepción de incumplimiento por parte del usuario, en este caso, no hace sino reafirmar el

¹⁰ “*Ste. Sopresur N.C.R. vs Sté Groupe Lebrun*” citado en Bergel, Salvador Dario, *Op. Cit* nota 4

¹¹ Eduardo Couture, “Fundamentos del derecho procesal civil”, Editorial IB de F, Bs As, 1998

carácter de carga de la presente, generando un perjuicio en su contra merced a su propio incumplimiento.

Por todo ello, el autor de la presente sostiene el carácter de carga del deber de informar en cabeza del usuario.

La Aplicación del principio de sistema y deber de consejo a nuestro derecho: Los casos “Sisteco S.A. c/ Sujoy” y “Sistex S.A. c/Oliva S.A.”

Si bien no existe en el país una legislación regulatoria del contrato informático, los institutos referidos en la misma han sido receptados en la jurisprudencia nacional en dos casos “*Sisteco S.A. c/ Sujoy*” fallado por la Cámara Nacional en lo comercial, Sala E en junio de 1986 y “*Sistex S.A. c/Oliva S.A.*” sentenciado por la suprema Corte de Mendoza Sala I en febrero de 1990.

En el primero de los fallos, la actora Sisteco S.A. demanda por cobro de pesos sobre el saldo impago de una compraventa de un equipo de computación celebrada en el año 1979. El demandado reconoció la existencia del contrato, oponiendo a la acción la excepción de incumplimiento por entender que la contraparte no había cumplido con la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

El caso presenta interés toda vez que recepta por primera vez el concepto de sistema como la correlación entre un universo material y un objetivo fijado de antemano. La cámara al fallar a favor del demandado, sostiene la procedencia de la excepción de incumplimiento por entender que “... *a los efectos de la aceptación del sistema adquirido y de la asunción de la obligación de pago, es necesaria la operación conforme del conjunto de elementos componentes del sistema y su utilidad y adecuación a los fines previstos*”¹²

De esta manera, la sentenciante modifica el concepto de entrega en los casos de equipos informáticos, requiriendo por parte de la proveedora no solo la mera transmisión de los bienes sino que los mismos cumplan con los objetivos previstos al momento de adquirirlos.

El segundo de los casos bajo análisis plantea los fundamentos del deber de consejo como asimismo marca pautas interpretatorias en relación a los supuestos de oscuridad.

En el extenso fallo de la doctora Kemelmajer de Carlucci analiza la existencia del desequilibrio técnico entre las partes. Al respecto sostiene que “*Aunque el adquirente o el usuario sea una persona avezada en el ramo comercial de su actividad, generalmente carece de suficientes conocimientos y experiencia en materia de utilización de equipos de elaboración electrónica de datos. En otros términos hay entre los contratantes una brecha tecnológica que se advierte en la tecnología empleada, poco comprensible para el hombre medio*”

Asimismo la sentenciante pone de manifiesto la existencia de una disparidad de objetivos entre las partes cuando sostiene que “*El usuario y el suministrados del servicio se aproximan a la negociación con actitudes radicalmente diferentes: El primero espera del contrato un cierto resultado funcional, el segundo en cambio, tiende a prometer una simple correspondencia del sistema de determinadas características y especificaciones técnicas*”

Finalmente el fallo extrae de esta situación de hecho la existencia de la obligación de información y consejo en cabeza del proveedor del servicio informático

¹² CNCom, Sala E, 26/6/86 “*Sisteco Sistemas de Computación S.A. c/Sujoy Sergio*”, LL 1987-A-137, ED 122-437.

en el considerando VII punto 4 in fine cuando expresa “... *Esta situación también se extrae la obligación de información y consejo que recae sobre el proveedor del servicio*”

Como puede observarse si bien la obligación de consejo no se haya legislado específicamente, es claro que existen elementos suficientes en ambos fallos como para realizar una construcción jurisprudencial del tema.

Los límites de la obligación de consejo:

Si admitimos entonces la existencia de una obligación de consejo y acordamos en su contenido, debemos por último definir cuales son los límites que dicha obligación mantiene. Al respecto y a los efectos de su estudio, debemos dividirlos en temporales y materiales.

En el aspecto temporal la obligación de consejo debe extenderse por toda la vida contractual: El fundamento de tal afirmación se encuentra en el art. 1198 de nuestro código civil: si sostenemos que los contratos deben necesariamente cumplirse e interpretarse de buena fe y asimismo admitimos que la obligación de consejo encuentra su fundamento en la buena fe lealtad debida entre las partes, es una conclusión lógica que, atento a su carácter derivad, la misma se extiende mientras exista este deber de comportamiento entre las partes.

Sin embargo, el contenido de la misma varía según estemos hablando de la etapa precontractual o durante la ejecución del contrato. En la etapa precontractual, el deber de consejo se refiere básicamente a la elección de los componentes del sistema y los materiales. En la etapa contractual, en cambio, dicha obligación se encuentra referida a la formación del personal, la reorganización del servicio y –en su caso- a la gestión de los componentes del sistema.

En referencia a los aspectos materiales del sistema, es necesario definir cuales son los campos específicos sobre los cuales debe versar el consejo. Frente a esto, es necesario realizar algunas precisiones.

En primer lugar, la obligación de consejo encuentra su fundamento en la diferencia de conocimiento técnico entre las partes contratantes. Ya hemos visto que, en los casos que esta diferenciación desaparece, ya sea por presencia de un tercero consultor o por las propias características del usuario, la obligación de consejo se encuentra limitada o desaparece¹³

En segundo lugar, el contenido de la carga encuentra su concreción en el carácter técnico del proveedor, atento a su función de traductor de las necesidades del cliente en un sistema que de cumplimiento a las mismas. La pretensión de ampliar la obligación de consejo a elementos fuera del área técnica violenta dicha función, confundiendo los papeles del proveedor y usuario, en referencia a la redacción de las necesidades y situaciones de hecho en que estas se desarrollan.

En tercer lugar, una ampliación violenta el principio de la buena fe, atento al hecho que implica la pretensión del usuario de que el proveedor asuma las riesgos y responsabilidades que se encuentran a su cargo.

Por último, la pretensión tornaría en antieconómica la contratación informática, al tener que asumir el proveedor un cúmulo indeterminado de responsabilidades.

¹³ Al respecto ver el punto 4 del presente trabajo

Por ende, esta parte entiende que el deber de consejo tiene sus límites materiales ceñidos a lo estrictamente técnico, sin que pueda reclamársele por errores que excedan dicho marco.

Así lo entendido la jurisprudencia francesa en autos *“Cajus Face vs IBM”* fallado por la Cámara de Apelaciones de París en fecha 10 de abril de 1974. En dicho fallo se exime a la demandada IBM de la responsabilidad derivada del error en el calculo de la rentabilidad del sistema, por entender que dichos datos exceden la esfera técnica entrando en la orbita de lo empresarial.

Garantías específicas de los contratos informáticos

Durante el cumplimiento de la prestación, en los contratos informáticos existen ciertas garantías propias de la categoría que la doctrina ha denominado *“compatibilidad”, “modularidad” y “escalabilidad”*.

La compatibilidad significa que el proveedor debe garantizar la adaptabilidad de los sistemas contratados al resto de los sistemas instalados por el usuario. Algunos autores sostienen que la compatibilidad debe darse entre los componentes mismos del sistema pero, a opinión del autor de la presente, resulta un requisito redundante: Un sistema por definición constituye un conjunto organizado de bienes informáticos que cumplen una función, por ende, si no pudieran funcionar entre sí, no estaríamos frente a un sistema.

Por escalabilidad se entiende la posibilidad de migrar el sistema entregado a arquitecturas superiores o distintas, lo que hoy adquiere una particular importancia atento la velocidad del cambio tecnológico, que incrementa rápidamente las exigencias de los equipamientos y los vuelve obsoletos.

Por último, la modularidad es la posibilidad del sistema entregado de funcionar en módulos independientes, que mantienen autonomía entre sí.

Con relación al soporte lógico, el proveedor informático debe asumir la defensa de las turbaciones de derecho que puedan producirse por la propiedad intelectual del software. Ello obedece a que el usuario no tiene porque indagar acerca de los derechos que se transmiten con el contrato y el caso que se originen reclamos derivados de los derechos de propiedad intelectual o industrial, el proveedor tiene la obligación de asumir su defensa.

El moderno concepto de entrega: el test de aceptación

Es importante tener presente que, atento el carácter específico de los contratos informáticos, cuando nos referimos a la entrega debemos distinguir la mera entrega física del sistema, del cumplimiento integral de la prestación, que requiere de la instalación y puesta en funcionamiento, el test de aceptación y su aprobación.

Entre los elementos a entregar por el proveedor deben incluirse los manuales y la documentación anexa que permita un funcionamiento satisfactorio de los equipos, para lo que es menester que se establezca en el contrato las especificaciones de los mismos. Esta documentación se considera parte del soporte físico y lógico y debe incluirse en el precio del contrato¹⁴.

Respecto de la obligación de puesta en marcha en sí, si nada dice el contrato, la misma constituye una carga del proveedor informático, salvo en los casos que el

¹⁴ Bergel, Salvador, *“Contratos Informáticos en el derecho privado”*, en Carrascosa Lopez (Dir), *“Informática y Derecho”*, UNED, Vol 8, Merida, España, 1995.

usuario cuente con un sector informático o haya contratado a un tercero para llevar a cabo la tarea.

En función de ello, los proveedores cumplirán con las prestaciones de conformidad con las normas técnicas aplicadas a los buenos usos de la práctica informática. El equipo físico y el lógico estarán libres de todo defecto debido a la concepción deficiente, la falta de competencia profesional o empleo de materiales defectuosos y cumplirá con las funciones establecidas en el contrato. El concepto de buenos usos en la práctica informática implica que las prestaciones deben ser cumplidas por el proveedor de conformidad con las normas, la tecnología, la concepción (arquitectura del sistema), la fabricación, el equipo lógico, etc, propios del estado de la técnica.

La forma de determinar la correcta puesta en funcionamiento del sistema es la realización del llamado test de aceptación. Se trata de una operación de verificación que se desarrolla para comprobar que el equipo supera ciertas exigencias preestablecidas que están relacionadas con el objeto de la prestación. En tal sentido, es conveniente que el usuario establezca la previsión contractual de no aceptar el equipo hasta que el proveedor haya probado que se han superado determinadas pruebas preestablecidas.

Esto significa que la obligación de pago del precio, en los contratos de adquisición de bienes informáticos, queda supeditada al cumplimiento de las especificaciones del test de aceptación. En función de ello, el mismo deberá elaborarse cuidadosamente estableciendo los parámetros de funcionamiento aceptable del sistema, los métodos de comunicación de los incumplimientos y las formas de solución de los problemas suscitados.

Un tema a tener en cuenta en la negociación del contrato son los plazos de comunicación de las objeciones. En particular desde el punto de vista del usuario el plazo debe permitir el análisis del sistema, así como la realización de los test que delimiten los límites de funcionamiento del sistema (cuantos archivos soporta, cuantos usuarios pueden conectarse al mismo tiempo, etc.). Desde el punto de vista del proveedor, el término debe permitir establecer el final del período de prueba, con prescindencia de la efectiva comunicación del usuario. En tal sentido, es usual la inclusión de una cláusula que especifique una aceptación ficta del sistema en el caso de inexistencia de objeciones vencido el plazo establecido, así como la obligación del usuario de comunicar las objeciones dentro plazo excepto en los casos que las mismas sean derivadas de las modificaciones introducidas durante el test de aceptación.